

Kurzkommentar Obligationenrecht I

Art. 41 OR

NICOLA MOSER/BEAT SCHÖNENBERGER, in:
Isabelle Wildhaber, Daniel Häusermann, Heinrich Honsell
Obligationenrecht
2. Auflage, 2026
Helbing Lichtenhahn Verlag, ISBN 978-3-7190-4182-3

Art. 41

A. Haftung im Allgemeinen

1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.

I. Voraussetzungen der Haftung

2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.

LITERATUR

ACKERMANN, Kausalität, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Unfall und Unfallversicherung, St. Gallen 2009, 29 ff.; DERS., Adäquanz und Vorhersehbarkeitsregel, Diss. Bern 2001; AEBI-MÜLLER/PFAFFINGER, Haftung für Rat und Auskunft, in: FS Vonplon, Zürich/Basel/Genf 2009, 21 ff.; BECK, Massenkollision und Schadenerledigung, Einleitung, HAVE 2010, 159 ff.; ANGELOZZI, La dualité de la causalité adéquate en assurance-accidents et en responsabilité civile sous l'angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles psychiques, SJ 2009, 181 ff.; BERGER, Der Geschädigte hat ein Anrecht auf [Seite 213] Ersatz seiner Anwaltskosten – Die Anwaltskosten im Haftpflichtprozess unter besonderer Berücksichtigung der Problematik des Überklagens, HAVE 2003, 131 ff.; BERGER-STEINER, Der Kausalitätsbeweis, in: HAVE Personen-Schaden-Forum 2009, Zürich 2009, 13 ff.; BERTHOUD, Le droit aux valeurs d'affectation, Diss. Freiburg i.Ue. 2008; BIERI, La faute au sens de l'article 41 CO, SJZ 2007, 289 ff.; BIERI, Sittenwidrige Schädigung nach Art. 41 Abs. 2 OR, AJP 2008, 549 ff.; BORIO, Haftpflichtrechtliche Herausforderungen bei autonomen Pflegerobotern, Pflegerecht 2021, 223 ff.; BORLE, Keine haftpflichtrechtliche Kausalität bei banalen Unfallereignissen, HAVE 2010, 135 ff.; BOSSHARD, Neuere Tendenzen in der Lehre zum Begriff der Widerrechtlichkeit nach Art. 41 OR, Zürich 1988; BRÜCKNER, Die Rechtfertigung des ärztlichen Eingriffs in die körperliche Integrität gem. Art. 28 Abs. 2 ZGB, ZSR 2000 I, 451 ff.; BRULHART, L'influence de la prédisposition constitutionnelle sur l'obligation de réparation du responsable, in: Werro (Hrsg.), La fixation de l'indemnité, Bern 2004, 89 ff.; BÜYÜKSAGIS, Responsabilité pour les systèmes d'intelligence artificielle, HAVE 2021, 12 ff.; BUCHER, Die Haftpflicht für Körperverletzungen im Teamsport – ein Lösungsansatz, QFLR 2018, 10 ff.; CAMPRUBI, Kontrahierungszwang gemäss BGE 129 III 35, ein Verstoss gegen die Wirtschaftsfreiheit, AJP 2004, 384 ff.; CARTIER, Begriff der Widerrechtlichkeit nach Art. 41 OR, Diss. St. Gallen 2007; CHAPPUIS B., Quelques dommages dits irréparables: réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine, SJ 2010, 165 ff.; CHAPPUIS, La distinction entre illicéité et la faute: n'est-il pas temps de reconcer?, in: FS Brehm, Bern 2012, 83 ff.; CHAPPUIS, Le préjudice ménager: encore et toujours ou les errances du dommage normatif, HAVE 2004, 282 ff.; CHAPPUIS/WERRO, La responsabilité civile: à la croisée des chemins, ZSR 2003 II, 237 ff.; CHAPPUIS/WINGER (Hrsg.), Le préjudice, une notion en devenir, Zürich 2005; CHAUDET/KOCH, Responsabilité pour les dommages réputés purement économiques, in: Etudes en l'honneur de B. Rusconi, Lausanne 2000, 59 ff.; CONTI, Die Malaise der ärztlichen Aufklärung, AJP 2000, 615 ff.; DELCÔ, Die Bedeutung des Grundsatzes von Treu und Glauben beim Ersatz reiner Vermögensschäden, Zürich 2000; DUPONT, Le dommage écologique, Bern 2005; DIES., Dommage, vers une nouvelle définition, SJ 2003 II, 471 ff.; DUC, Accident type «coup de lapin» et causalité en responsabilité civile, HAVE 2009, 87 ff.; ELSIG/DUC, Causalité adéquate ou inadéquate à la responsabilité civile?, HAVE 2007, 217 ff.; FAVRE, La notion de force majeure et de cas fortuit, en relation avec les événements naturels, dans la régime de la responsabilité civile privée ou de droit public, Sicherheit & Recht 2009, 193 ff.; FELLMANN, Widerrechtlichkeit: Drei Theorien für ein Problem, Versuch einer Zwischenbilanz, ZSR 2009 I, 473 ff.; DERS., Normativierung des Personenschadens – der Richter als Gesetzgeber?, in: HAVE

Personen-Schaden-Forum 2005, Zürich 2005, 13 ff. (zit. Personen-Schaden-Forum); DERS., Neuere Entwicklungen im Haftpflichtrecht, **AJP 1995, 878 ff.**; FISCHER, Ausservertragliche Haftung für Schockschäden Dritter, Zürich 1988; **[Seite 214]** DERS., Dritthaftung für falsche freiwillige Auskünfte, ZVglRWiss 1984, 1 ff.; FLÜHMANN, Haftung aus Prüfung und Berichterstattung gegenüber Dritten, Bern 2004; FRIDL/KAUFMANN, Vorprozessuale Anwaltskosten – aus Sicht der Berner Geschädigtenvertretung, **HAVE 2012, 493 ff.**; FRIEDRICH, La responsabilité du sportif dans ses rapports avec d'autres sportifs: thèmes choisis selon le droit actuel et selon l'avant-projet de révision du droit de la responsabilité civile, in: Foëx/Werro (Hrsg.), La réforme du droit de la responsabilité civile, Zürich 2004, 219 ff.; GABRIEL, Die Widerrechtlichkeit in **Art. 41 Abs. 1 OR** unter Berücksichtigung des Ersatzes reiner Vermögensschäden, Diss. Freiburg i.Ue. 1987; GALLI, Kausalität bei psychischen Störungen im Deliktsrecht, Basel 2007; GASSER, Kausalität und Zurechnung von Information als Rechtsproblem, Diss. St. Gallen 2001; GATTIKER, Die Verletzung der Aufklärungspflicht und ihre Folgen, in: Fellmann/Polodna (Hrsg.), Die Haftung des Arztes und des Spitals, Zürich 2003, 111 ff.; DIES., Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht, Zürich 1999; GAUCH, Der Schätzer und die Dritten, in: FS Wiegand, Bern 2005, 823 ff. (zit. FS Wiegand); DERS., Grundbegriffe des ausservertraglichen Haftpflichtrechts, recht 1996, 225 ff.; DERS., Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltskosten, recht 1994, 189 ff.; GAUCH/SWEET, Deliktschaftung für reinen Vermögensschaden, in: FS Keller, Zürich 1989, 117 ff.; GHIRINGHELLI, Risarcibilità delle vacanze impedito o rovinato, Collezione Assista, Genf 1998, 174 ff.; GIGER, Grundprinzipien der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit, Strassenverkehr 2/2022, 5 ff.; DERS., Analyse der Adäquanzproblematik im Haftpflichtrecht, in: FS Keller, Zürich 1989, 141 ff.; DERS., Berührungspunkte zwischen Widerrechtlichkeit und Verschulden, Jubiläumsschrift «100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht», Freiburg i.Ue. 1982, 369 ff. (zit. Berührungspunkte); GIOVANNONI, Le dommage indirect en droit suisse de la responsabilité civile, ZSR 1977 II, 31 ff.; GIRSBERGER, Behandlung von Schäden aus Risikosportarten, in: Rechtsschutz im Privatrecht, Symposium für Richard Frank, Zürich 2003, 53 ff.; GÖKSU, Gedanken zur Kontrahierungspflicht anlässlich von **BGE 129 III 35**, ZBJV 2004, 35 ff.; GORDON/LUTZ, Haftung für automatisierte Entscheidungen – Herausforderungen in der Praxis, SZW 2020, 53 ff.; GUILLIOD, Responsabilité médicale de la faute objectivée à l'absence de faute, in: Chappuis/Winiger (Hrsg.), Responsabilités objectives, Journée de la responsabilité civile 2002, Zürich 2003, 155 ff.; GUROVITS, Die zivilrechtliche Haftung für Zuschauerverhalten, CaS 2014, 267 ff.; HAFTER, Rechtfertigende Einwilligung bei mehrpersonenbetreffenden Persönlichkeitsverletzungen, recht 2021, 1 ff.; HAUSHEER, Neuere Entwicklungen beim Schadensausgleich im Bereiche der Familie, insb. zum Haushalt- und «Scheidungsschaden», in: FS Widmer, Wien 2003, 113 ff.; DERS., Unsorgfältige Behandlung, in: Münch/Geiser (Hrsg.), Schaden – Haftung – Versicherung, Basel/Genf/München 1999, 719 ff.; HEFTI, Deliktsrechtliche Klimaklage in der Schweiz, ex ante 2023, 72 ff.; HÄNSENBERGER, Wenn Drohnen vom Himmel fallen – luftrechtliche **[Seite 215]** Haftungsfragen, **AJP 2017, 163 ff.**; HERZOG-ZWITTER, Kind als Schaden, **HAVE 2012, 150 ff.**; DIES., Schwacher adäquater Kausalzusammenhang, Intensität, Unfallschwere und weitere Aspekte, Urteil des Bundesgerichts **4C.402/2006** vom 27. Februar 2007, HAVE 2007, 357 ff.; DIES., Haushaltschaden, normativer Schadensbegriff und der allgemeine Rechtsgrundsatz der Schadensminderungspflicht im Haftpflichtrecht, HAVE 2005, 275 ff.; HERZOG-ZWITTER/HAA/NEUHAUS-DESCUVES, Haftpflichtrecht: Wegfall einer einmal gegebenen natürlichen Kausalität, HAVE 2009, 32 ff.; HOFSTETTER, Gutachterhaftung gegenüber Dritten im schweizerischen Recht, **AJP 1998, 261 ff.**; HONSELL, Differenztheorie und normativer Schadensbegriff, in: FS SGHVR, Zürich 2010, 255 ff.; DERS., Das Kind als Schaden, in: FS Bucher, Bern 2009, 275 ff.; DERS., Die Haftung für Auskunft und Gutachten, insb. gegenüber Dritten, in: FS Nobel, Bern 2005, 939 ff.; DERS., Die Haftung für Auskunft und Gutachten, insb. gegenüber Dritten, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht und Versicherungsrechtstagung, St. Gallen 2005, 169 ff.; HÜRLIMANN, Die Haftung des Liegenschaftsschätzers gegenüber einem vertragsfremden Dritten, BR 2004, 105 ff.; HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, Die Vertrauenshaftung aus der Sicht eines praktizierenden Anwalts, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 2005, St. Gallen 2005, 199 ff.; IDERKUM, Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe aus Persönlichkeitsverletzung, Diss. Freiburg i.Ue. 2008; JÄGGI, Gutachten zur Frage der Entschädigung eines invaliden Ordensbruders, HAVE 2004, 245 ff.; JANIS, Hypothetische Einwilligung und Aufklärung über Operationsrisiken, HAVE 2003, 145 ff.; JANSSEN, Das Angehörigenschmerzengeld in Europa und dessen Entwicklung – Verpasst Deutschland den Anschluss?, ZRP 2003, 156 ff.; JENNY/TUOR, Ausserprozessuale Anwaltskosten – ein Schaden kommt selten allein, Anwaltsrevue 2022, 249 ff.; KELLER, Das unerwünschte Kind als Schaden?, HAVE 2006, 414 f.; KELLER, Ist eine Treu und Glauben verletzende Schädigung widerrechtlich?, recht 1987, 136 f.; KERNEN, Das Geldwäschereigesetz als Quelle von haftpflichtrechtlichen «Schutznormen»,

recht 2008, 133 ff.; KISSLING, Dogmatische Begründung des Haushaltschadens, Diss. Bern 2006; KLETT, Vertragsfreiheit und Kontrahierungszwang, BJM 2005, 161 ff.; KOLLER, Grundzüge der Haftung für reinen Vermögensschaden, **AJP 2020, 1381** ff.; DERS., Dritthaftung einer Vertragspartei – Vertragliche und ausservertragliche Haftung im Überblick, in: Neue und alte Fragen zum privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004, 1 ff.; KRAMER, Schleudertrauma: Das Kausalitätsproblem im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, BJM 2001, 153 ff.; DERS., Die Kausalität im Haftpflichtrecht: Neue Tendenzen in Theorie und Praxis, ZBJV 1987, 289, 306 ff.; DERS., «Reine Vermögensschäden» als Folge von Stromkabelbeschädigungen, recht 1984, 128 ff.; KRAUSKOPF, Spielregeln und ihre Bedeutung für das Deliktsrecht, **HAVE 2020, 180** ff.; KUHN, Die Haftung aus falscher Auskunft und falscher Raterteilung, SJZ 1986, 345 ff.; LANDOLT, Haftung für rechtmässiges Alternativverhalten, **HAVE 2014, 3** ff.; DERS., Er **[Seite 216]** satzpflicht für «Schockschäden», in: FS Schwander, Zürich 2011, 361 ff.; DERS., Aktuelles zum Pflege-, Betreuungs- und Besuchsschaden, HAVE 2011, 3 ff.; DERS., Der Unternehmerschaden, Zürich/St.Gallen 2011; DERS., Der Nichtvermögensschaden: Ersatzpflicht für immaterielle, normative und fiktive Schäden, in: FS SGHVR, Zürich 2010, 341 ff.; DERS., Kausalität und Verkehrsunfall, in: Schaffhauser (Hrsg.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, St. Gallen 2010, 145 ff.; DERS., Angehörigenschaden: Reflex- oder Direktschaden – oder sogar beides? HAVE 2009, 3 ff.; DERS., Perte d'une chance – verlorene oder vertane Chance?, HAVE 2008, 68 ff.; DERS., Ausservertragliche Haftung einer Vertragspartei für die Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, St. Gallen 2005, 23 ff.; DERS., Der Pflegeschaden, in: HAVE Personen-Schaden-Forum 2003, Zürich 2003, 67 ff.; LORANDI, Haftung für reinen Vermögensschaden, recht 1990, 19 ff.; LOSER, Ausservertragliche Haftung einer Vertragspartei für reine Vermögensschäden, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungstagung, St. Gallen 2005, 111 ff.; DERS., Kausalitätsprobleme bei der Haftung für Umweltschäden, Bern/Stuttgart 1994; DERS., Schadenersatz für wahrscheinliche Kausalität, **AJP 1994, 954** ff.; LÜCHINGER, Schadenersatz im Vertragsrecht, Freiburg i.Ue. 1999 (Nachdruck 2006); MANAI, Le devoir d'information du médecin en procès, SJ 2000 II, 341 ff.; MANNSDORFER, Haftung für pränatale Schädigung des Kindes, ZBJV 2001, 605 ff.; DERS., Pränatale Schädigung, Ausservertragliche Ansprüche pränatal geschädigter Personen; unter Berücksichtigung der Rechtslage im Ausland, insbesondere in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, Freiburg i.Ue. 2000; MAUCHLE, Die ausservertragliche Haftung des Veranstalters bei Ausschreitungen im Fussball, **HAVE 2016, 296** ff.; MEIER-SCHATZ, Über die privatrechtliche Haftung für Rat und Anlagerat, in: FS Piotet, Bern 1990, 151 ff.; MEIERHANS, Der immer noch nicht bewältigte Reflexschaden, recht 1994, 202 ff.; MERZ, Die Widerrechtlichkeit gem. **Art. 41 OR** als Rechtsquellenproblem, in: Berner Festgabe für den Schweizerischen Juristenverein, Bern 1955, 301 ff.; MISTELI, La responsabilité pour le dommage purement économique, Zürich 1999; MÖCKLI/REBER, Bankhaftung bei pflichtwidriger externer Vermögensverwaltung, recht 2023, 152 ff.; MOSER, Die Haftung gegenüber vertragsfremden Dritten, Bern 1998; MÜLLER/BACHMANN, Treu und Glauben als grundrechtliche Vermögensschutznorm?, SJZ 2020, 259 ff.; MÜLLER, Unterhaltskosten für ein ungeplantes Kind als Schaden, SZGR 2008, 51 ff.; DERS., La perte d'une chance, in: Foëx/Werro (Hrsg.), La réforme du droit de la responsabilité civile, Zürich 2004, 143 ff.; DERS., Die ärztliche Haftpflicht für die Geburt eines unerwünschten behinderten Kindes, **AJP 2003, 522** ff.; DERS., La perte d'une chance, Bern 2002; DERS., Schadenersatz für verlorene Chancen – Ei des Kolumbus oder Trojanisches Pferd?, **AJP 2002, 389** ff.; MÜLLER-CHEN, Probleme des dualistischen Haftungskonzepts, in: Fellmann/Weber (Hrsg.), Haftpflichtprozess 2008, Zürich 2008, 13 ff.; DERS., Haftpflichtrecht in der Krise?, **[Seite 217]** BJM 2002, 289 ff.; NICOD, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, Diss. Lausanne 1987; OVERNEY, Illicéité de résultat et illicéité de comportement, une distinction dépassée?, in: FS Brehm, Bern 2012, 281 ff.; PERGOLIS/DÜRR BRUNNER, Ungereimtheiten beim Haushaltschaden, HAVE 2005, 202 ff.; PERREN, Zur Daseinsberechtigung der Drittschadensliquidation, ZBJV 2004, 58 ff.; PERRIG, Die Drittschadensliquidation – braucht es sie?, QFLR 2024, 14 ff.; PETITPIERRE, Le préjudice patrimonial et le tort moral: vers de nouvelles frontières?, in: Chappuis/Winiger (Hrsg.), Le Préjudice, Zürich 2004, 63 ff.; PEYER, Zur Ersatzfähigkeit reiner Vermögensschäden, recht 2002, 99 ff.; POLEDNA, Arzt- und Spitalhaftung vor neueren Entwicklungen – ein Überblick, in: Fellmann/Poledna (Hrsg.), Die Haftung des Arztes und des Spitals, Zürich 2003, 111 ff.; PORTMANN, Erfolgsunrecht oder Verhaltensunrecht? Zugleich ein Beitrag zur Abgrenzung von Widerrechtlichkeit und Verschulden im Haftpflichtrecht, SJZ 1997, 273 ff.; PRIBNOW/WIDMER/SOUSA-POZA/GEISER, Die Bestimmung des Haushaltschadens auf der Basis der SAKE, HAVE 2002, 24 ff.; PROBST, Der Ersatz «immateriellen Schadens» im schweizerischen Haftpflicht- und Strassenverkehrsrecht, in: Werro/Probst (Hrsg.), Strassenverkehrsrechtstagung 10.–11. Juni 2010, Bern 2010, 1 ff.; QUADRONI, Künstliche Intelligenz – praktische Haftungsfragen, **HAVE 2021, 345** ff.; RASCHEIN, Deliktsrechtliche Ersatzfähigkeit reiner Nutzungsbeeinträchtigungen

an Sachen – Ein künftiges Diskussionsthema in der Schweiz?, in: FS Widmer, Wien 2003, 283 ff.; DERS., Die Widerrechtlichkeit im System des schweizerischen Haftpflichtrechts, Diss. Bern 1985; RIESEN, Skiunfälle in der Schweiz, **HAVE 2022, 327 ff.**; ROBERTO, Ersatzpflicht für verdorbenen Feriengenuss, **HAVE 2016, 276 ff.**; DERS., Verschulden statt Adäquanz – oder sollte es gar die Rechtswidrigkeit sein?, recht 2002, 145 ff.; DERS., Deliktsrechtlicher Schutz des Vermögens, **AJP 1999, 511 ff.**; ROBERTO/GRECHENIG, Zurechnungsprobleme im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht – die Rolle der Adäquanz, in: HAVE Personen-Schaden-Forum 2009, Zürich 2009, 55 ff.; ROBERTO/REICHLE, Ein Vierteljahrhundert Vertrauenshaftung, **AJP 2019, 1105 ff.**; DIES., Haftung für «Phantom-Beschwerden»? **HAVE 2013, 3 ff.**; ROBERTO/RICKENBACH, Was ist eine Schutznorm? ZSR 2012 I, 185 ff.; ROGGO, Aufklärung des Patienten: eine ärztliche Informationspflicht, Bern 2002; RONCORONI/SCHÖBL, «Volenti non fit iniuria», in: FS Widmer, Wien 2003, 319 ff.; RÜETSCHLI, Aurea mediocritas – Gedanken zum Begriff der mittleren Fahrlässigkeit, HAVE 2009, 137 ff.; DERS., Haftung für fehlgeschlagene Sterilisation, **AJP 1999, 1359 ff.**; SCHMID, Natürliche und adäquate Kausalität im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in: Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, St. Gallen 1997, 183 ff.; SCHÖNENBERGER, Die dritte Widerrechtlichkeitstheorie, HAVE 2004, 3 ff.; DERS., Haftung für Rat und Auskunft gegenüber Dritten, Basel 1999 (zit. Rat und Auskunft); SCHWARZ, Zivilrechtliche Haftung für Geldwäscherei, HAVE 2009, 9 ff.; SCHWENZER, Rechtsverfolgungskosten als Schaden, in: FS Tercier, Genf 2008, **[Seite 218]** 417 ff.; DIES., Rezeption deutschen Rechtsdenkens im schweizerischen Obligationenrecht, in: Schwenger (Hrsg.), Schuldrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Tübingen 1999, 59 ff.; SCHWENZER/SCHÖNENBERGER, Civil Liability for Purely Economic Loss in Switzerland, in: Swiss reports presented at the XVth International Congress of Comparative Law, Zürich 1998, 353 ff.; STÄHLE, «Bewährte Lehre» (**Art. 1 Abs. 3 ZGB**), Diss. Zürich 2023; STARK, Zur Frage der Schädigungen ohne Vermögensnachteile, in: FS Keller, Zürich 1989, 311 ff.; STEINER, Das «Kind als Schaden» – ein Lösungsvorschlag, ZBJV 2001, 646 ff.; STUDER/JUVET/ZANONI, Schockschaden – eine herausfordernde Zurechnungsfrage, **HAVE 2019, 219 ff.**; SUMMERMATTER, Vereitelte Chancen und gesteigerte Risiken als Anknüpfungspunkt zivilrechtlicher Haftung, **HAVE 2014, 244 ff.**; TERCIER, De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages, in: FS Assista, Genève 1979, 247 ff.; VERDE, Haftungsbegründung anhand strafrechtlicher Schutznormen, **HAVE 2016, 141 ff.**; DERS., Haftung für Arbeitszeugnis, Empfehlungsschreiben, Referenzauskunft und Referenzschreiben, recht 2010, 144 ff.; DERS., Straftatbestände als Schutznormen im Sinne des Haftpflichtrechts, Diss. Zürich 2014 (zit. Straftatbestände); VERMOT, La causalité, HAVE 2006, 83 ff.; VON GRAFFENRIED, Schadloshaltung des Dritten in zweivertraglichen Dreiparteienverhältnissen, Diss. Bern 2019; WERRO, Du dommage ménager au dommage monacal ou de la relativisation du dommage normatif, HAVE 2004, 247 ff.; DERS., Le préjudice: une notion dans la mouvance des conceptions, in: Chappuis/Winiger (Hrsg.), Le préjudice, Zürich 2004, 125 ff.; DERS., Haftung für fehlerhafte Auskunft und Beratung – braucht es die Rechtsfigur der Vertrauenshaftung, recht 2003, 12 ff.; DERS., Die Sorgfaltspflichtverletzung als Haftungsgrund nach **Art. 41 OR**: Plädoyer für ein modifiziertes Verständnis von Widerrechtlichkeit und Verschulden in der Haftpflicht, ZSR 1997 I, 343 ff.; DERS., Tort Liability for Pure Economic Loss: A Critique of Current Trends in Swiss Law, in: Banakas (Hrsg.), Civil Liability für Pure Economic Loss, London/The Hague/Boston 1996, 181 ff.; WIDMER, Vertrauenshaftung – Von der Gefährlichkeit des Überflüssigen, ZSR 2001 I, 101 ff.; WIDMER, Die Vereinheitlichung des schweizerischen Haftpflichtrechts – Brennpunkte eines Projektes, ZBJV 1994, 385 ff.; WINIGER, Une définition ambivalente et 2000 ans de confusion: illicéité objective et subjective, in: FS Wessner, Basel 2011, 265 ff.; WYSS, Kausalitätsfragen unter besonderer Berücksichtigung der hypothetischen Kausalität, SJZ 1997, 313 ff.; ZEDER, Haftungsbefreiung durch Einwilligung des Geschädigten, Diss. Basel 1999; vgl. ausserdem weitere allg. Literatur zum Deliktsrecht bei den Vorbem. zu Art. 41–61 und zu den Rechtfertigungsgründen bei Art. 52.

[Seite 219] I. Allgemeine Verschuldenshaftung (Abs. 1)

1. Charakter der Norm

Art. 41 Abs. 1 enthält die **Grundnorm** der ausservertraglichen Verschuldenshaftung. **1**
Der schweizerische Gesetzgeber hat sich damit für die Form einer **Generalklausel** entschieden. Dies offenbart sich insb. in der fehlenden Definition des Begriffs der Widerrechtlichkeit (vgl. SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.02; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 03.01; vgl. zur Widerrechtlichkeit nachfolgend N 21 ff.). Die Form der Generalklausel entspricht dem Vorbild von Art. 1382 code civil (vgl. ZK-MOSER/SCHÖNENBERGER, **Art. 41 OR** N 1).

2. (Haftungs-)Voraussetzungen

Die h.L. geht im Rahmen von Art. 41 Abs. 1 von vier Haftungsvoraussetzungen aus: **Schaden, Kausalität, Widerrechtlichkeit und Verschulden** (vgl. nur **CR CO I-WERRO/PERRITAZ, Art. 41 N 6**; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.01; KELLER, I, 132; ebenso die Darstellungen bei **BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 3 ff.**). Eine Mindermeinung, die an Stelle des Schadens eine Rechtsgutsverletzung als Haftungsvoraussetzung sieht und das Element des Schadens nur auf der Rechtsfolgenseite diskutiert (i.d.S. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 03.04 ff.), hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Im Rahmen des zu Schadenersatz verpflichtenden Art. 41 Abs. 1 ist diese Sichtweise verzichtbar. Allerdings spielt die Rechtsgutsverletzung als Haftungsvoraussetzung insb. dann eine Rolle, wenn nicht Schadenersatz (in Geld) als Rechtsfolge vorgesehen ist (z.B. Art. 47, 49). Das Element der Rechtsgutsverletzung spielt des Weiteren im Rahmen der Diskussion der Kausalität (vgl. N 13) sowie bei der Einteilung der Schadensarten (vgl. N 10 f.) eine Rolle. Dieser Theorienstreit wird jedoch dadurch abgemildert, dass im Einklang mit den ältesten Kommentierungen (ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, **Art. 41 OR N 2**; BK-BECKER, **Art. 41 OR N 1**) nicht von vier, sondern von fünf Haftungsvoraussetzungen auszugehen ist. Zusätzlich zu den vorgenannten Voraussetzungen ist an erster Stelle eine **schädigende Handlung** erforderlich.

Die **schädigende Handlung** kann in einer positiven Handlung oder in einer Unterlassung bestehen. Diese Unterscheidung ist v.a. im Zusammenhang mit der Kausalität von Bedeutung (vgl. hierzu nachfolgend, N 13). Es kann jedoch vorweggenommen werden, dass eine Unterlassung nur dann als schädigende Handlung gewertet werden kann, wenn eine Rechtspflicht zu einem bestimmten Handeln besteht (vgl. nur BK-BECKER, **Art. 41 OR N 2**). Von einer schädigenden Handlung kann im Zusammenhang mit dem Haftpflichtrecht nur dann gesprochen werden, wenn diese zu einer **Rechtsgutsverletzung** führt (ähnlich ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 05.01 ff.). Zu den Rechtsgütern zählen vorerst die sog. **absolut geschützten Rechtsgüter**, die eine Ausschluss- und [Seite 220] Abwehrwirkung gegenüber jedermann entfalten (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.05). Hierzu zählen persönliche Rechtsgüter (Leben, Gesundheit, körperliche und psychische Unversehrtheit, Freiheit, Persönlichkeitsrechte), dingliche Rechte (Eigentum und beschränkte dingliche Rechte) sowie Immaterialgüterrechte. Andererseits stellt auch das **Vermögen an sich** ein Rechtsgut dar, wenn auch kein absolut geschütztes (unrichtig daher **BGE 118 Ib 473 E. 2b**: «Das Vermögen als solches ist kein Rechtsgut»). Daher kann eine Rechtsgutsverletzung ebenso in einer Verminderung des Vermögens bestehen. Die Art der Rechtsgutsverletzung spielt bei der Einteilung der verschiedenen Schadensarten (vgl. N 10 f.) sowie insb. im Zusammenhang mit der Frage der Widerrechtlichkeit (vgl. N 21 ff.) eine Rolle.

Im Gegensatz zum normalen Sprachgebrauch stellt die vorgenannte Rechtsgutsverletzung für sich allein keinen Schaden im Rechtssinn dar (vgl. nur OFTINGER/STARK, I, § 2 N 1; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.03). Der **Schaden** im Rechtssinn entspricht vielmehr einer ungewollten Vermögensverminderung (Verminderung des Reinvermögens), die in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven (*damnum emergens*) oder in entgangenem Gewinn (*lucrum cessans*) bestehen kann. Nach der sog. **Differenzhypothese** (Differenzmethode, Differenztheorie) entspricht der Schaden damit der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (vgl. **BGE 132 III 321 E. 2.2.1**). Nicht in Geld messbare Beeinträchtigungen (Nichtvermögensschäden) sind nach dieser Schadensdefinition daher grundsätzlich nicht ersatzfähig; dies betrifft insb. die so genannte immaterielle Unbill (*tort moral*), aber auch die Beeinträchtigung des Affektionsinteresses (vgl. zur Ausnahme bei Tieren, Art. 43 N 14), Einbusse an

Freizeit oder entgangener Feriengenuss (BGE 115 II 474 E. 3a). Immaterielle Unbill kann allenfalls einen Anspruch auf Genugtuung auslösen (Art. 47, 49).

Nach der bundesgerichtlichen Rsp. (BGE 132 III 359, mit zahlreichen Nw. zur Lehre) stellen die **Unterhaltskosten für ein unerwünschtes Kind** zweifelsfrei einen ersatzfähigen Schaden im Rechtssinne dar (CR CO I-WERRO/PERRITAZ, Art. 41 N 29 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.04; RÜETSCHLI, AJP 1999, 1365 ff.; vgl. zum Ganzen auch die Beiträge in HAVE 2006, 414 ff.).

Grundsätzlich gelten auch **Anwaltskosten** als Schadensposten. Ersatzfähig sind sie jedoch nur, soweit sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht durch die zivilprozessuale Parteientschädigung gedeckt sind (vgl. nur BGE 117 II 101 E. 6b; BGer 4A_264/2015, E. 3 und 4.2.1 f.). Ausgeschlossen ist somit ein Schadenersatzanspruch für Anwaltskosten, welche gem. Art. 95 Abs. 3 ZPO in die Prozesskosten einfließen. Dies gilt selbst dann, wenn das Zivilprozessrecht keine Parteientschädigung vorsieht (vgl. BGE 139 III 190). Praktisch bedeutsam ist die Geltendmachung von Anwaltskosten [Seite 221] als Schadensposition deshalb in erster Linie in Haftpflichtfällen, welche aussergerichtlich erledigt werden. Hier kann der Geschädigte seine (regelmässig unumgänglichen) ausserprozessualen Anwaltskosten auf den Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer überwälzen. Dies gilt auch für die Kosten, welche in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren entstanden sind (JENNY/TUOR, 250 f.).

Der Verlust einer blossen Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu vermeiden (*perte d'une chance*) kann nach bundesgerichtlicher Rsp. nicht als Vermögensschaden anerkannt werden (BGE 133 III 462 E. 4.4.3, m.w.N. zur Literatur insb. E. 4.2). Damit wird auch eine Haftung nach Wahrscheinlichkeitsgrad abgelehnt (BGE 133 III 462 E. 4.2/4.4.3).

Unter dem Begriff des **normativen Schadens** wird in der Lehre versucht, die Differenzhypothese wertend zu konkretisieren bzw. zu korrigieren (vgl. REY/WILDHABER, N 193), sodass Nachteile auch dann als ersatzfähig zu gelten haben, wenn keine eigentliche Vermögensverminderung vorliegt (vgl. CR CO I-WERRO/PERRITAZ, Art. 41 N 21 ff.; REY/WILDHABER, N 193 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.05 ff.). Erscheinungsformen des normativen Schadensbegriffs sind der Kommerzialisierungsschaden, der Frustrationsschaden sowie der ökonomisch strukturierte Schadensbegriff (vgl. FELLMANN, HAVE Personen-Schaden-Forum 2005, 17 ff.). Während der Kommerzialisierungsgedanke gewisse Nutzungsmöglichkeiten einer Sache (unabhängig von seiner tatsächlichen Nutzung) kommerzialisiert, zielt der Frustrationsgedanke auf die Ersatzfähigkeit von Aufwendungen, die sich im Nachhinein als nutzlos erweisen, da ein erhoffter Genuss ausbleibt. Der ökonomisch strukturierte Schadensbegriff stellt eine Kombination der beiden anderen Theorien dar und bezweckt Schadenersatz im Falle der Beeinträchtigung einer abstrakten Gebrauchsmöglichkeit (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.08; FELLMANN/KOTTMANN, N 84). In der Schweiz stossen diese Relativierungen des traditionellen Schadensbegriffs weitgehend auf Ablehnung. Eine Ausnahme stellen der sog. **Haushaltsschaden** sowie der **Pflege- und Betreuungsschaden** dar (vgl. hierzu OFK-FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, Art. 41 OR N 20; FELLMANN, HAVE Personen-Schaden-Forum 2005, 21 ff. m.w.N.). So anerkennt das BGer einen ersatzfähigen Schaden auch dann, wenn Hausarbeiten nicht durch eine bezahlte Haushaltshilfe, sondern durch Mehrarbeit der anderen Familienangehörigen geleistet wird (BGE 132 III 321 E. 3.1; 127 III 403 E. 4). Dasselbe gilt im Falle des Pflegeschadens, wenn eine geschädigte Person zu Hause unentgeltlich von Familienangehörigen gepflegt wird (BGE 132 III 327 E. 3.2.2; BGer 4C.276/2001, E. 6). Eine weitergehende Anerkennung von abstrakten Nutzungsbeeinträchtigungen wird in der Schweiz zumindest im

ausservertraglichen Haftpflichtrecht weitgehend abgelehnt (vgl. hierzu etwa OFK-FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, Art. 41 OR N 21 m.w.N.).

[Seite 222] Schäden können nach unterschiedlichen Kriterien in verschiedene **Arten** eingeteilt werden. Im ausservertraglichen Haftpflichtrecht spielen die Einteilung in Personen-, Sach- und reine Vermögensschäden auf der einen und die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Schäden auf der anderen Seite eine Rolle. Die Unterscheidung zwischen **unmittelbaren und mittelbaren Schäden**, welche die entstandenen Schäden je nach der Länge der sie verursachenden Kausalkette unterscheidet (vgl. hierzu insb. BGE 133 III 257), ist im Deliktsrecht hingegen bedeutungslos (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.27 f.; BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 7; FELLMANN/KOTTMANN, N 138; diff. ZK-LANDOLT, Vor Art. 45/46 OR, N 95 ff.).

Die Einteilung von Schäden kann an die Frage anknüpfen, welches Rechtsgut durch die schädigende Handlung verletzt wurde und somit zu einer Vermögensverminderung geführt hat. Ein **Personenschaden** (Körperschaden) ist demnach diejenige Vermögenseinbusse, die auf die Tötung oder Verletzung eines Menschen zurückzuführen ist. Ein **Sachschaden** liegt dann vor, wenn der Grund in der Beschädigung, Zerstörung oder dem Verlust einer Sache liegt. Der **reine Vermögensschaden** besteht in der Vermögensverminderung, die weder als Personen- noch als Sachschaden qualifiziert werden kann. Es handelt sich somit um denjenigen Schaden, der weder auf der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen noch auf der Beschädigung, Zerstörung oder dem Verlust einer Sache beruht (vgl. BGE 133 III 323 E. 5.1). Beim reinen Vermögensschaden fallen die Rechtsgutsverletzung und der Schaden damit zusammen (ausdr. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 05.66). Die Einteilung in Personen-, Sach- und reine Vermögensschäden ist in erster Linie im Zusammenhang mit der Begründung der Widerrechtlichkeit von Bedeutung (vgl. N 21). Im Übrigen spielt die Unterscheidung bei gewissen Spezialhaftungen eine Rolle, welche ihren Anwendungsbereich tlw. von vornherein auf gewisse Schadenskategorien begrenzen (vgl. z.B. den Ausschluss reiner Vermögensschäden im Rahmen von Art. 58 Abs. 1 SVG).

Bei der Unterscheidung zwischen **direkten und indirekten Schäden** geht es um die Frage der Person des Geschädigten. Direkt geschädigt ist derjenige, der wegen der primären Einwirkung auf seine Rechtsgüter einen Schaden erlitten hat. Von einem indirekten Schaden (sog. **Reflexschaden**; Drittschaden) ist dann die Rede, wenn eine Vermögensverminderung deshalb entsteht, weil eine andere Person eine primäre Rechtsgutsverletzung erlitten hat (vgl. REY/WILDHABER, N 412 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.19 ff.). Im Interesse der Klarheit sollte auf eine synonyme Verwendung des Begriffspaares mittelbarer/unmittelbarer Schaden verzichtet werden (so aber BGE 131 III 306 E. 3.1.1). Nach der h.A. ist für Reflexschaden grundsätzlich **kein Schadenersatz** zu leisten (vgl. BGE 131 III 306 E. 3.1.1; BGer 4A.408/2008, E. 7.; 4C.413/2006, E. 4; REY/WILDHABER, N 415). Dies wird allgemein damit begründet, dass der Gesetzgeber in Art. 45 Abs. 3 für den Versorgerschaden [Seite 223] ausnahmsweise eine Ersatzpflicht angeordnet habe (vgl. BGE 112 II 118 E. 5b; 127 III 403 E. 4b/aa). Dieser Grundsatz wurde aber in der Rsp. tlw. durchbrochen. So ist neben dem Versorgerschaden ausnahmsweise ein Reflexschaden zu ersetzen, wenn der Schädiger eine besondere Verhaltensnorm verletzt, deren Zweck darin besteht, Schutz vor Schäden von der Art des eingetretenen zu gewähren (REY/WILDHABER, N 419). Bekannt geworden sind diesbzgl. insb. die sog. **Kabelbruchfälle** (vgl. BGE 102 II 85 E. 5; BGE 106 II 75 E. 2; vgl. auch N 23). Allerdings werden damit die Fragen der Widerrechtlichkeit und des (direkten) Schadens unnötigerweise vermischt (vgl. N 23). Von einem indirekten Schaden wird tlw. auch im Zusammenhang mit dem sog. **Schockschaden** gesprochen. Dieser tritt ein, wenn aufgrund eines plötzlichen, lebensbedrohlichen oder angsteinflössenden Ereignisses eine andere Person derart erschreckt wird, dass deren psychischen Folgen das Leben negativ beeinflussen. Der Schockschaden überschreitet die Schwelle zur widerrechtlichen Körper- oder

Persönlichkeitsverletzung und ist dadurch von der Angehörigengenußung (Art. 47/49) abzugrenzen (vgl. JANSSEN, 157). Das BGer bejahte den entsprechenden Anspruch eines Vaters, der darüber benachrichtigt wurde, dass seine zwei Söhne durch herunterfallende Wrackteile eines Militärflugzeugs erschlagen wurden (BGE 112 II 118). Auch eine Ehefrau, welche mit ansehen musste, wie ihr Ehemann auf der Unfallstelle verblutete, konnte ihren Schockschaden geltend machen (BGer 4A_423/2008). Schliesslich wurde auch den Eltern eines 17-jährigen Autounfallopfers, die mit der Todesnachricht konfrontiert wurden, ein entsprechender Anspruch eingeräumt (BGE 138 III 276). Bei genauer Betrachtung ist es jedoch verfehlt, den Schockschaden als Reflexschaden zu betrachten. Es handelt sich dabei vielmehr um einen direkten Schaden (REY/WILDHABER, N 411; OFK-FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, Art. 41 OR N 31). Vgl. ausführlich zu den Schockschäden STUDER/JUVET/ZANONI, HAVE 2019, 219 ff. Es wäre zu begrüssen, das **Dogma der Nichtersatzfähigkeit von Reflexschäden** aufzugeben. Eine Begrenzung der Ersatzpflicht für Reflexschäden ergibt sich schon genügend aus der Tatsache, dass es sich i.d.R. um reine Vermögensschäden handelt. Im Ergebnis geht es somit um die Begründung der Widerrechtlichkeit (krit. auch SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.22; FELLMANN/KOTTMANN, N 144 ff.).

Im Rahmen der Theorie der **Drittschadensliquidation** geht es im ausservertraglichen Kontext um Fälle, in denen die in ihren Rechtsgütern verletzte Person und der Geschädigte vollständig auseinanderfallen (vgl. VON GRAFFENRIED, N 563; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.24). Sie unterscheiden sich von den Reflexschäden dadurch, dass keine direkt geschädigte Person existiert. Der Schaden tritt rechnerisch vielmehr notwendigerweise im Vermögen einer Drittperson ein (OFK-FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, Art. 41 OR N 12; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 14.24). Die Problematik stellt sich etwa [Seite 224] bei Gegenständen, welche im Eigentum einer Leasinggeberin stehen, für welche jedoch der Leasingnehmer das Erhaltungsrisiko trägt (vgl. VON GRAFFENRIED, N 729). In der Lehre wird geltend gemacht, dass es unbillig wäre, wenn der Geschädigte seinen Schaden in solchen Konstellationen (mangels Widerrechtlichkeit) nicht gegenüber dem Schädiger geltend machen könnte. Dementsprechend wird etwa im erwähnten Bsp. des indirekten Leasings unter dem Titel der Drittschadensliquidation dafür plädiert, dem Leasingnehmer die Aktivlegitimation für die Geltendmachung von Schäden am Leasingobjekt zuzusprechen (vgl. VON GRAFFENRIED, N 730 f.). Vom BGer wurde die Zulässigkeit der Drittschadensliquidation bisher offengelassen (BGer 4A_422/2010, E. 2.6). In der Lehre setzt sich jedoch zu Recht zunehmend die Auffassung durch, dass die Theorie der Drittschadensliquidation ihre Daseinsberechtigung hat (vgl. STÄHLE, 55 m.N.). Zwar böten für die Schadloshaltung gegebenenfalls auch der Vertrag zugunsten Dritter i.S.v. Art. 112, die Figur des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und eine Erweiterung des Deliktsrechts mögliche Lösungsansätze (vgl. hierzu VON GRAFFENRIED, N 820). Die mittlerweile gut erforschte Figur der Drittschadensliquidation stellt jedoch den besten Ansatz zur umfassenden Lösung der Problematik dar (vgl. auch PERRIG, QFLR 2024 17).

12

Als weitere Voraussetzung muss ein **Kausalzusammenhang** zwischen der schädigenden Handlung und dem Schaden bestehen. Ein Teil der Lehre unterscheidet hierbei noch genauer zwischen dem Kausalzusammenhang von schädigender Handlung und Rechtsgutsverletzung (haftungsbegründende Kausalität) und dem Kausalzusammenhang von Rechtsgutsverletzung und eingetretenem Schaden (haftungsausfüllende Kausalität; vgl. OFTINGER/STARK, I, § 3 N 20; BK-BREHM, Art. 41 OR N 103; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 19.01; diff. FELLMANN/KOTTMANN, N 420). Nach der hier vertretenen Auffassung ist die haftungsbegründende Kausalität bereits Teil des Elements der schädigenden Handlung (vgl. N 3). Die Prüfung des Kausalitätserfordernisses geschieht nach der h.M. in zwei Etappen: Nach der Prüfung der sog. **natürlichen Kausalität** ist die Frage

13

des sog. **adäquaten Kausalzusammenhangs** zu beantworten (vgl. nur BK-BREHM, Art. 41 OR N 104).

Natürliche Kausalität liegt dann vor, wenn die schädigende Handlung eine notwendige Bedingung für den eingetretenen Schaden darstellt. Nach der sog. *conditio sine qua non*-Formel kann somit die schädigende Handlung nicht hinweggedacht werden, ohne dass der eingetretene Erfolg (Schaden) entfielen (vgl. nur BGE 132 III 715 E. 2.2; REY/WILDHABER, N 621 m.w.N.). Gemäss der allg. Beweisregel von Art. 8 ZGB ist die Existenz des natürlichen Kausalzusammenhangs vom Geschädigten zu beweisen. Obwohl sich der natürliche Kausalzusammenhang grundsätzlich nach naturgesetzlichen Kriterien beurteilt, sind an den Beweis keine allzu strengen Anforderungen zu stellen; es genügt der Beweis der **überwiegenden Wahrscheinlichkeit** (vgl. nur [Seite 225] BGE 128 III 271 E. 2b/aa; 107 II 269 E. 1b; vgl. zur Prospekthaftung BGE 132 III 715 E. 3.2; vgl. auch SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, N 83 f.). Die Feststellung des natürlichen Kausalzusammenhangs ist eine vom BGER nicht überprüfbare Tatfrage (BGE 131 III 306 E. 3.2.1; BGER 4C.402/2006, E. 3). Abgelehnt wird eine Haftung nach Wahrscheinlichkeitsgrad entsprechend der Rechtsfigur der *perte d'une chance*, (vgl. N 79).

Da eine blossе Ursachenzuordnung nach Massgabe der natürlichen Kausalität uferlos wäre (vgl. z.B. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 3), bedarf es einer Beschränkung der haftungsrelevanten Ursachen nach Wertungskriterien (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 19.02). Dies geschieht in erster Linie mittels der **Adäquanztheorie**. Demnach liegt ein adäquater Kausalzusammenhang dann vor, wenn die Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt des Erfolges also durch die Ursache als allgemein begünstigt erscheint (vgl. BGE 123 III 110 E. 3a; BK-BREHM, Art. 41 OR N 121). Bei der Adäquanztheorie geht es hauptsächlich um eine **Begrenzung der Haftung** (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 120). Die Beurteilung der Adäquanz ist im Haftpflichtrecht weniger streng als im Sozialversicherungsrecht (BGE 123 III 110 E. 3a-c; BGER 4C.50/2006, E. 4; 4A_45/2009, E. 3.3.2; REY/WILDHABER, N 640). Die adäquate Kausalität kann im Haftpflichtrecht auch dann gegeben sein, wenn diese sozialversicherungsrechtlich verneint wird (ausdrücklich KELLER, I, 83). Die Frage der adäquaten Kausalität ist eine vom BGER überprüfbare Rechtsfrage (BGE 132 III 715 E. 2.2; 123 III 110 E. 2). Demgemäss kommen die Beweislastvorschriften von Art. 8 ZGB auf den adäquaten Kausalzusammenhang nicht zur Anwendung. Als Rechtsfrage ist die Adäquanz keinem Beweis zugänglich. Allerdings sind aus der Rsp. abweichende Entscheide bekannt, in welchem vom Geschädigten der entsprechende Beweis (zu Unrecht) verlangt wurde (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 122 m.N.). Die Adäquanztheorie wird in der Lehre schon seit längerer Zeit kritisiert (vgl. REY/WILDHABER, N 663 m.w.N.). An ihrer Stelle soll daher nach der **Schutzzwecktheorie** (Normzwecktheorie, Lehre vom Rechtswidrigkeitszusammenhang) durch Auslegung der verletzten Norm bestimmt werden, für welche Rechtsgutsverletzungen bzw. Schäden ein Schädiger einzustehen hat (vgl. REY/WILDHABER, N 665 m.w.N.). Die Frage des Ausmasses der verletzten Schutzpflicht betrifft nach dieser Theorie das Tatbestandselement der Widerrechtlichkeit (vgl. N 21; ROBERTO, Haftpflichtrecht, 04.103 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 19.08).

Nach der h.L. und Rsp. kann ein adäquater Kausalzusammenhang durch eine neue Ursache **unterbrochen** werden. Dies ist nach der Rsp. dann der Fall, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend [Seite 226] ist die Intensität der beiden Ursachen (BGE 143 II 661 E. 7.1; 142 IV 237 E. 1.5.2; 130 III 182 E. 5.4; 116 II 519 E. 4b). Als **Unterbrechungsgründe** kommen höhere Gewalt, grobes Selbstverschulden des Geschädigten und grobes Drittverschulden in Frage (BGER

4A_302/2020, E. 5.2). Höhere Gewalt ist ein unvorhersehbares, aussergewöhnliches Ereignis, das mit unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbricht (BGE 102 Ib 257 E. 5; 111 II 429 E. 1b). Dieser Unterbrechungsgrund hat in der Rsp. nur geringe Bedeutung (vgl. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.42 m.N.). Im Übrigen ist dieser Einwand bei einer Verschuldenshaftung ohnehin bedeutungslos, da in einem solchen Fall kein Verschulden vorliegt; allenfalls geht es um ein Problem der überholenden Kausalität (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 143). Das Selbstverschulden des Geschädigten oder ein Drittverschulden muss jeweils eine erhebliche Intensität aufweisen, damit ein adäquater Kausalzusammenhang unterbrochen werden kann. Beide Fallgruppen spielen i.d.R. nur bei Kausalhaftungen eine Rolle (vgl. die Nw. bei BK-BREHM, Art. 41 OR N 139 ff.; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.43 f.). Beim Selbstverschulden kommt anstelle einer Unterbrechung des Kausalzusammenhangs auch eine Reduktion des Schadenersatzes nach Art. 44 Abs. 1 in Frage. Unter anderem aus diesem Grunde lehnt ein Teil der Lehre die Figur der Unterbrechung des Kausalzusammenhangs ab (vgl. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 37; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 20.03 ff.; diff. FELLMANN/KOTTMANN, N 471 ff.). In der Tat erscheint die Unterbrechung eines adäquaten Kausalzusammenhangs widersprüchlich, denn entweder liegt rechtlich adäquate Kausalität vor oder nicht (vgl. schon BGE 86 IV 153 E. 1). Dogmatisch einleuchtender wäre es, in solchen Fällen die Adäquanz zu verneinen (HUGUENIN, OR AT/BT, N 1929; OFK-FISCHER/BÖHME/GÄHWILER, Art. 41 OR N 71).

Besondere Fragen im Zusammenhang mit der Kausalität stellen sich dann, wenn mehrere Schadensursachen vorhanden sind. Diese Problematik zeigt sich zum einen bei der sog. **alternativen Kausalität**, wenn mehrere Ursachen für eine Schadenszufügung kausal sein können, im konkreten Fall aber nur eine tatsächlich kausal geworden ist. Heute aktuelle Fälle aus dem Bereich der alternativen Kausalität zeigen sich insb. im Bereich der Umwelt- oder Produkthaftpflicht (i.d.S. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 21.03). Nach der traditionellen, streng an die Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB anknüpfenden Meinung kann in diesen Fällen schon mangels Beweises der Verursachung keine Haftung begründet werden (vgl. ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 41 OR N 87; BK-BREHM, Art. 41 OR N 145). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wurde schon nach der älteren Lehre in Fällen bewussten Zusammenwirkens der möglichen Schadensverursacher gemacht (z.B. beim Raufhandel, vgl. BGE 57 II 417 E. 2), wo Solidarität nach Art. 50 Abs. 1 angenommen wurde (vgl. m.N. BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 25). Die heute wohl überwiegende Lehre will nun auch in den Fällen ohne bewusstes Zusammenwirken neue Lösungsansätze finden. Vorschläge gehen von einer solidarischen Haftung aller möglichen Schadensverursacher in Analogie zu Art. 51 Abs. 1 (vgl. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 3 N 67), über eine Haftung nach wahrscheinlicher Verursacherquote (vgl. REY/WILDHABER, N 744), über eine Umkehr der Beweislast in Bezug auf die kausale Verursachung (ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.29; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, N 108) bis hin zur anteilmässigen Haftung entsprechend dem Marktanteil (market share liability; vgl. CR CO I-WERRO/PERRITAZ, Art. 41 N 55).

Bei der sog. **kumulativen Kausalität** setzen mehrere Schädiger unabhängig voneinander Schadensursachen, wobei jede Ursache den Schadenseintritt allein hätte bewirken können (vgl. REY/WILDHABER, N 732 ff.). Nach einhelliger Auffassung in der Lehre kann in diesem Fall jeder Verursacher für den ganzen Schaden solidarisch haftbar gemacht werden (vgl. REY/WILDHABER, N 734 m.w.N.). Insofern wird bei der kumulativen Kausalität von der strengen Anwendung der *conditio sine qua non*-Formel Abstand genommen. Einen Spezialfall stellt die Konstellation dar, in welcher sowohl der Schädiger als auch der Geschädigte den Gesamtschaden verursacht haben. Nach richtiger Auffassung haftet der Schädiger auch hier,

17

18

allerdings ist die Schadenersatzpflicht in Anwendung von Art. 43/44 ggf. zu reduzieren (so auch REY/WILDHABER, N 738).

Bei der sog. **überholenden (hypothetischen) Kausalität** entfaltet eine Ursache, die zu einer Rechtsgutsverletzung bzw. zu einem Schaden führen würde, ihre Wirkung nur deshalb nicht, weil die gleiche Rechtsgutsverletzung (bzw. Schaden) **zuvor** durch eine zweite adäquate Ursache bewirkt wird. Die sich in Gang befindliche Kausalkette wird daher durch eine zweite überholt. Die damit nicht wirksam gewordene Ursache wird damit bloss zur **Reserveursache** und ist grundsätzlich haftpflichtrechtlich nicht relevant (BK-BREHM, Art. 41 OR N 147a; BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 26 m.w.N.). Das BGer will die hypothetische Kausalität jedoch aufgrund wertender Gesichtspunkte berücksichtigen (BGE 115 II 440 E. 4b). Nach der neueren Lehre ist die Problematik der überholenden Kausalität ein Problem der **Schadensberechnung** (so REY/WILDHABER, N 728). Dem entspricht insb. auch die Rsp. zur Frage der **konstitutionellen Prädisposition**, sofern sich die vorbestehende Gesundheitsschädigung auch ohne das schädigende Ereignis ausgewirkt hätte (vgl. BGE 131 III 12 E. 4; 113 II 86 E. 1b; BGer 4C.49/2007, E. 5.1.1; 4C.402/2006, E. 5.1; vgl. ZK-LANDOLT, Art. 46 OR, N 874 ff.). Eine ähnliche Konstellation liegt beim sog. **rechtmässigen Alternativverhalten** vor (vgl. REY/WILDHABER, N 765 ff.; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.24 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 21.07; FELLMANN/KOTTMANN, N 510 ff.). Hierbei beruft sich der Schädiger darauf, dass der Schaden auch dann eingetreten wäre, wenn er sich rechtmässig verhalten hätte. Relevant wird die Frage oftmals im Zusammenhang mit einer pflichtwidrigen Unterlassung (REY/WILDHABER, N 766). Das entsprechende [Seite 228] Argument wird in der Praxis regelmässig bei Arzthaftungsprozessen vorgebracht. Willigte ein Patient mangels Aufklärung nicht in eine Behandlung ein, kann der Arzt einwenden, dass die Einwilligung (hypothetisch) auch erfolgt wäre, wenn über die in der Folge relevanten Risiken aufgeklärt worden wäre. Diesfalls muss der Patient glaubhaft machen oder wenigstens die persönlichen Gründe anführen, warum er sich der Operation widersetzt hätte, wenn er die Risiken gekannt hätte (BGer 4A_160/2015, E. 5.2.2.; grundlegend BGE 122 III 229 E. a/aa). Explizit vorgesehen ist die Entlastungsmöglichkeit des rechtmässigen Alternativverhaltens in Art. 56, wonach der Tierhalter nachweisen kann, dass der Schaden auch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt eingetreten wäre (vgl. für ein Bsp. Art. 56 N 14).

Wird dem Schädiger eine **Unterlassung** vorgeworfen, so kann diese streng naturwissenschaftlich betrachtet nie kausal sein (vgl. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 06.09). Rechtlich kann eine Unterlassung aber dann als kausal für eine Rechtsgutsverletzung (bzw. einen Schaden) betrachtet werden, wenn eine Pflicht zum Handeln bestanden hätte. Bei einem Unterlassen ist somit danach zu fragen, ob durch pflichtgemässes Handeln die Rechtsgutsverletzung bzw. der Schaden hätte vermieden werden können (vgl. BGE 124 III 155 E. 3d). Die Kausalitätsprüfung geschieht daher in zwei Schritten. Zuerst ist zu prüfen, ob eine Pflicht zum schadensverhindernden Handeln besteht. Danach ist zu fragen, ob die Rechtsgutsverletzung bzw. der Schaden bei Vornahme dieser gebotenen Handlung hätte verhindert werden können. Grundsätzlich unterscheidet die Rsp. auch hier zwischen natürlichem und adäquatem Kausalzusammenhang. Während bei Handlungen die wertenden Gesichtspunkte erst bei der Beurteilung der Adäquanz zum Tragen kommen, spielen diese Gesichtspunkte bei Unterlassungen i.d.R. aber schon bei der Feststellung des hypothetischen Kausalverlaufs eine Rolle. Es ist daher bei Unterlassungen i.d.R. nicht sinnvoll, den festgestellten oder angenommenen hypothetischen Geschehensablauf auch noch auf seine Adäquanz zu prüfen. Die Feststellungen des Sachrichters im Zusammenhang mit Unterlassungen sind daher entsprechend der allgemeinen Regel über die Verbindlichkeit der Feststellungen zum natürlichen Kausalzusammenhang für das BGer bindend. Nur wenn die hypothetische Kausalität ausschliesslich gestützt auf die allgemeine Lebenserfahrung – und nicht gestützt auf Beweismittel – festgestellt wird, unterliegt sie der Überprüfung durch das BGer (BGE 132 III 715, E. 2.3; BGer 4A_87/2019,

E. 4.1.3.). Als Beweismass ist auch bei Unterlassungen die überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichend (BGE 124 III 155 E. 3d; BK-BREHM, Art. 41 OR N 119). Bei der zentralen Frage der Pflicht zum Handeln geht es im Wesentlichen nicht um eine Frage der Kausalität, sondern um die Begründung der Widerrechtlichkeit: Nach dem sog. **Gefahrensatz** hat derjenige, der einen gefährlichen Zustand schafft oder unterhält, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen Schutzmassnahmen zu ergreifen. Der [Seite 229] Gefahrensatz ist bei der Verletzung von absoluten Rechtsgütern – im Gegensatz zu reinen Vermögensschäden (BGE 124 III 297, E. 5b) – geeignet, bei Fehlen einer spezifischen Schutznorm eine Widerrechtlichkeit zu begründen (BGer 4A_104/2012, E. 2.1).

Die **Widerrechtlichkeit** (Rechtswidrigkeit) hat die Funktion der Haftungsbegrenzung, indem sie haftungsbegründendes (d.h. i.d.R. zu Schadenersatz verpflichtendes) Unrecht von hinzunehmenden Nachteilen unterscheidet (vgl. SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.04; REY/WILDHABER, N 789 ff.). Der schweizerische Gesetzgeber hat auf eine Legaldefinition der Widerrechtlichkeit verzichtet (vgl. GAUCH, FS Wiegand, 838; GIGER, Berührungspunkte, 377 f.). Bis etwa Mitte der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts fanden sich hauptsächlich zwei Theorien zur Definition der Widerrechtlichkeit. Es waren dies die sog. subjektive Widerrechtlichkeitstheorie und die sog. objektive Widerrechtlichkeitstheorie. Seit etwa 30 Jahren wird in der Lehre sodann eine dritte Widerrechtlichkeitstheorie diskutiert. 21

Die **subjektive Widerrechtlichkeitstheorie** geht von der grundsätzlichen Widerrechtlichkeit jeder Schadenszufügung aus, es sei denn, der Schädiger verfüge über eine besondere subjektive Berechtigung. Diese Theorie stützt sich hauptsächlich auf den französischen Wortlaut der entsprechenden Norm des Obligationenrechts in der Fassung von 1881 (Art. 50 aOR: *quiconque cause sans droit un dommage...*). Im Haftpflichtrecht gilt diese Definition der Widerrechtlichkeit heute allg. als überholt (vgl. REY/WILDHABER, N 808 ff. m.w.N.; a.A. GABRIEL, N 898 ff.). Hingegen hat sie im Rahmen von Art. 28 Abs. 2 ZGB nach wie vor Gültigkeit (vgl. BSK ZGB I-MEILI, Art. 28 ZGB N 45). 22

Die wohl immer noch überwiegende Lehre, v.a. jedoch das BGer vertreten die **objektive Widerrechtlichkeitstheorie** (vgl. nur BGE 133 III 323 E. 5.1; 123 II 577 E. 4b; 123 III 306 E. 4a; 122 III 176 E. 7b; 119 II 127 E. 3; 115 II E. 3a). Nach dieser Theorie ist eine Schadenszufügung widerrechtlich, wenn sie gegen eine allg. gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht des Geschädigten beeinträchtigt (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine Norm bewirkt wird, die nach ihrem Zweck vor derartigen Schäden schützen soll (Verhaltensunrecht). Verkürzt gesagt liegt Widerrechtlichkeit demnach bei der Verletzung absoluter Rechte oder beim Verstoss gegen eine das Vermögen schützende Norm vor (vgl. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 3). Bei der Verletzung absoluter Rechte ist eine schädigende Handlung somit automatisch als widerrechtlich zu qualifizieren, gleichgültig wie sich der Schädiger dabei verhalten hat bzw. ob er dabei gegen eine Rechtsnorm verstossen hat. Demgegenüber bedarf es eines spezifisch zu begründenden Verhaltensunrechts, wenn durch die schädigende Handlung lediglich das Vermögen betroffen wurde. Hierbei besteht die Widerrechtlichkeit im Verstoss gegen eine das Vermögen schützende [Seite 230] Norm (vgl. m.N. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 4; SCHWENZER/FOUNTOLAKIS, N 50.28). Damit ist die Qualifikation des Schadens von entscheidender Bedeutung, da Körper- und Sachschäden wegen Verstosses gegen ein absolutes Recht i.d.R. rechtswidrig sind. Bei reinen Vermögensschäden ist demgegenüber im Grundsatz keine Widerrechtlichkeit gegeben, es sei denn, es liege ein Verstoss gegen eine das Vermögen schützende Norm vor (vgl. REY/WILDHABER, N 799 m.w.N.). Solche Schutznormen finden sich v.a. im Vermögensstrafrecht und im Wettbewerbsrecht. Gemäss BGer haben etwa Art. 239 Abs. 2 StGB (BGE 102 II 85) oder Art. 305^{bis} StGB (BGE 133 III 323) Schutznormcharakter. Erfüllt sein muss diesbezüglich nach der 23

Rsp. auch der subjektive Tatbestand (BGE 133 III 323 E. 5.2), was in der neueren Lehre kritisiert wird (VERDE, Straftatbestände, N 368). Keine Schutznorm stellt der Grundsatz von Treu und Glauben gem. Art. 2 Abs. 1 ZGB dar (BGE 121 III 350 E. 6b; 108 II 305 E. 2b; vgl. m.N. zu Mindermeinungen SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.22). Nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob das **Löschen von elektronischen Daten** eine Sachbeschädigung darstellt und damit widerrechtlich ist. Ein namhafter Teil der Lehre befürwortet dies jedoch (so z.B. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.16a; REY/WILDHABER, N 368; WERRO, N 98; a.M. HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 18).

Im Bereich der Haftung für **unrichtige Rat- und Auskunftserteilung** hat das BGer den Grundsatz entwickelt, dass ausservertraglich schadenersatzpflichtig wird, wer aufgrund seines Fachwissens in Anspruch genommen wird, wunschgemäss Auskünfte erteilt und dabei wider besseres Wissen oder leichtfertig unrichtige Angaben macht, welche den in Frage stehenden Entschluss beeinflussen können (BGE 116 II 695 E. 4). Grundlage der Widerrechtlichkeit soll dabei eine **ungeschriebene Schutznorm** sein (BGE 111 II 471 E. 3; vgl. auch REY/WILDHABER, N 884). Bei genauer Betrachtung hat das BGer die Schutznormtheorie mit einer solchen Rsp. aber bereits verlassen und die Widerrechtlichkeit an situationsspezifische Pflichten zum Schutze des Vermögens angeknüpft (i.d.S. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 6).

In der neueren Lehre wird die Lehre vom Erfolgsunrecht zunehmend abgelehnt (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.31; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 04.08 ff., WERRO, N 339 ff.; REY/WILDHABER, N 822; SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 6 ff.; FELLMANN/KOTTMANN, N 334 ff.). Widerrechtlichkeit wird dabei unabhängig von der Art des verletzten Rechtsguts – d.h. auch bei der Verletzung absoluter Rechte – als Verletzung einer Verhaltenspflicht definiert. Damit können reine Vermögensschäden im Grundsatz gleich behandelt werden wie Körper- und Sachschäden. Entscheidend ist vielmehr die Frage nach dem Ausmass der verletzten Schutzpflicht als Widerrechtlichkeitsbegründung (i.d.S. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.04, 50.31).

[Seite 231] Im Ergebnis resultiert daraus die sog. **dritte Widerrechtlichkeitstheorie**. Diese definiert die Widerrechtlichkeit als Verletzung einer gegenüber dem Geschädigten bestehenden Sorgfalts- oder Schutzpflicht (i.d.S. insb. CR CO I- WERRO/PERRITAZ, Art. 41 N 87 ff.; WERRO, ZSR 1997 I, 343 ff.; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 04.48 ff.; SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 3 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.04, 50.31). Diese Theorie hat den Vorteil, dass reine Vermögensschäden – entsprechend dem Gesetzestext – nicht von vornherein diskriminiert werden. Andererseits entfällt auch der Automatismus der Widerrechtlichkeit bei der Verletzung absoluter Rechtsgüter (vgl. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 7 ff.). Die genaue Definition der dritten Widerrechtlichkeitstheorie ist noch nicht einheitlich. Es finden sich insb. zwei leicht unterschiedliche Ansätze (vgl. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 9 ff.). Während ein Teil der Lehre Widerrechtlichkeit als Verletzung einer Sorgfaltspflicht definiert (insb. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 04.57 ff.; WIDMER, 101, 111), definiert sie ein anderer Teil leicht diff. als Verletzung einer Schutzpflicht (so SCHÖNENBERGER, Rat und Auskunft, 107; DERS., HAVE 2004, 11 f.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.04; HOFSTETTER, 261 ff., 266). Bei der Definition als Sorgfaltspflichtverletzung ergibt sich allerdings eine Verschmelzung der Widerrechtlichkeit mit der objektiven Seite des Verschuldens. Diese Sichtweise ist nicht nur aus gesetzessystematischen Gründen abzulehnen (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 52a f. m.w.N.), sondern sie ist auch im Hinblick auf das Notwehr- und Nothilferecht sowie in Bezug auf das Widerrechtlichkeitserfordernis bei Gefährdungshaftungen problematisch (vgl. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 11 f.). Damit ist diejenige Definition der dritten Widerrechtlichkeitstheorie vorzuziehen, welche Widerrechtlichkeit als Verletzung einer gegenüber dem Geschädigten bestehenden **Schutzpflicht** definiert (vgl. SCHÖNENBERGER, HAVE 2004, 12). Diese Schutzpflichten sind fallgruppenweise herauszuarbeiten (vgl. bspw. zur ausservertraglichen Auskunftshaftung SCHÖNENBERGER, 153 ff., 177). Die dritte Widerrechtlichkeitstheorie hat sich bis heute in der bundesgerichtlichen Rsp. nicht

durchgesetzt (vgl. GAUCH, FS Wiegand, 838; krit. z.B. HÜRLIMANN/SIEGENTHALER, 199 ff., 212 ff.). Stattdessen wurden Rechtsfiguren zwischen Vertrag und Delikt, wie insb. die Vertrauenshaftung, entwickelt.

Widerrechtlichkeit ist ausgeschlossen, wenn **Rechtfertigungsgründe** vorliegen (vgl. 27 nur REY/WILDHABER, N 905 ff.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 5; BK-BREHM, Art. 41 OR N 60 ff.). Als Rechtfertigungsgründe kommen in Frage: Notwehr, Notstand und Selbsthilfe gem. Art. 52 (vgl. hierzu Art. 52), besondere privatrechtliche Befugnisse, die Ausübung öffentlicher Gewalt sowie die Einwilligung. Eingriffe in Rechtsgüter im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt (z.B. Betreibungsbeamte, Polizisten bei der Verhaftung) sind dann gerechtfertigt, wenn die Amtshandlung in rechtmässiger Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt und in der Kompetenz des betreffenden Beamten liegt. Hierbei obliegen dem Beamten die Achtung des pflichtgemässen Ermessens und die [Seite 232] Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (vgl. REY/WILDHABER, N 906 m.w.N.). Zu beachten ist indes, dass im eidg. oder kant. Recht auch eine Haftung für pflichtgemässe Schädigungen vorgesehen sein kann (REY/WILDHABER, N 907). Zu den die Widerrechtlichkeit ausschliessenden besonderen privatrechtlichen Befugnissen zählen insb. Art. 301 ZGB, Art. 701 ZGB sowie Art. 926 ZGB. Des Weiteren zählen auch private Pfändungs- bzw. Retentionsrechte dazu (vgl. Bsp. bei BK-BREHM, Art. 41 OR N 62).

Der wichtigste Rechtfertigungsgrund ist die **Einwilligung**. Diese setzt zu ihrer 28 Gültigkeit die Handlungsfähigkeit und bei Verfügungen über höchstpersönlichen Rechte i.S.v. Art. 19c ZGB die Urteilsfähigkeit des einwilligenden Verletzten voraus (vgl. hierzu BK-BREHM, Art. 41 OR N 63 ff.; REY/WILDHABER, N 913 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.36 ff.). Die Einwilligung in eine Persönlichkeitsverletzung ist nur in den Grenzen von Art. 27 ZGB möglich. Nach Art. 27 ZGB unzulässig sind sowohl übermässige Verpflichtungen als auch solche, die den höchstpersönlichen Kernbereich der Persönlichkeit betreffen. In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob in den betroffenen Persönlichkeitsbereichen überhaupt von einer Disponibilität ausgegangen werden kann. Im Kernbereich der Persönlichkeit, z.B. bei der körperlichen Bewegungsfreiheit, der physischen und psychischen Integrität und der Intimsphäre, besteht ein absoluter Bindungsausschluss, weshalb eine gültige vertragliche Vereinbarung ausgeschlossen ist. Besteht demgegenüber die grundsätzliche Möglichkeit einer vertraglichen Verpflichtung, ist in einem zweiten Schritt das konkrete Rechtsgeschäft daraufhin zu überprüfen, ob die Bindung an sich – z.B. in zeitlicher Hinsicht – übermässig ist. Davon zu unterscheiden ist eine dritte Kategorie von nicht durchsetzbaren Verträgen, bei welchen die Verwerflichkeit (Sittenwidrigkeit) in deren Inhalt liegt. Einer rechtlichen Verbindlichkeit solcher Verträge stehen objektive Gesichtspunkte der Moral und der guten Sitten entgegen. Die Gültigkeit dieser Verträge richtet sich nach Art. 20 (BGE 136 III 401 E. 5.4). Ist eine Einwilligung unwirksam, greift allenfalls der Herabsetzungstatbestand von Art. 44 Abs. 1 (vgl. FELLMANN/KOTTMANN, N 380). Im Bereich des **Arzthaftungsrechts** bedingt die gültige Einwilligung in den Eingriff in die körperliche Integrität eine ordnungsgemässe Aufklärung durch den Arzt. Erforderlich ist dabei eine Information über die Risiken des Eingriffs (vgl. BGE 133 III 121 E. 4.1; 119 II 456 E. 2a; 108 II 59 E. 2). Eine weitere Bedeutung kommt der Einwilligung auch bei **Sportverletzungen** zu. In der Lehre ist umstritten, inwieweit bei Kontaktsportarten auf eine (echte) Einwilligung in die dadurch möglicherweise hervorgerufenen Verletzungen geschlossen werden kann (mit Ausnahme von Kampfsportarten generell **abl.** REY/WILDHABER, N 928; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 50.39; diff. ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 04.138, welcher das Konzept der Einwilligung als Haftungsausschlussgrund lediglich bei groben, nicht jedoch bei leichten Regelverstössen ablehnt **a.A.** THALER, Sportregeln, 160, welcher da [Seite 233] für plädiert, das Konzept der Einwilligung gänzlich, also auch bei Kampfsportarten, aufzugeben; vgl. zur Thematik auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 5 N 21). Nach der bundesgerichtlichen Rsp. darf jedenfalls dann keine Einwilligung in das der sportlichen Tätigkeit innewohnende Risiko einer Körperverletzung

angenommen werden, wenn eine den Schutz der Spieler vor Verletzungen bezweckende Spielregel absichtlich oder in grober Weise missachtet wurde (BGE 121 IV 249 E. 4.). Allgemein kann gesagt werden: «Je schwerer oder ungewöhnlicher der Spielregelverstoss einer Spielerin ist, desto eher liegt der Schluss nahe, dass er ausserhalb dessen liegt, was die geschädigte Spielerin als Gefahr des Spiels auf sich zu nehmen akzeptiert» (KRAUSKOPF, HAVE 2020, 182 f.).

Als weitere Haftungsvoraussetzung verlangt der Gesetzestext, dass die Schadenszufügung mit Absicht oder aus Fahrlässigkeit verursacht wurde («... sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit ...»). Den Haftpflichtigen muss somit ein **Verschulden** treffen. Verschulden ist die rechtliche Tadelnswürdigkeit eines Verhaltens (Tun oder Unterlassen; vgl. KELLER, I, 115). Dem Haftpflichtigen muss daher ein persönlicher Vorwurf für die Verursachung des Schadens gemacht werden können (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.01). Das Verschulden spielt in erster Linie eine Rolle als Haftungsvoraussetzung bei der deliktischen und vertraglichen Verschuldenshaftung. Des Weiteren ist es auch im Rahmen der Schadenersatzbemessung (Art. 43/44) von Bedeutung (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 167; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.02). Das Verschulden weist eine subjektive und eine objektive Komponente auf. Währenddem es bei der subjektiven Seite um die Frage der Urteilsfähigkeit der handelnden Person geht, hat die objektive Seite die Abweichung von einem unter den gegebenen Umständen angebrachten Durchschnittsverhalten zum Thema (vgl. nur HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 6 N 4).

Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die handelnde Person muss somit in der Lage sein, das Unrecht ihres Verhaltens zu erkennen und entsprechend dieser Einsicht zu handeln (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.04). Die Urteilsfähigkeit als grundsätzliche Haftungsvoraussetzung ergibt sich aus Art. 18 ZGB. Bei fehlender Urteilsfähigkeit kommt eine Haftung allenfalls aufgrund Art. 54 Abs. 1 in Betracht (vgl. zur vorübergehenden Urteilsfähigkeit Art. 54 Abs. 2, Art. 54 N 2 ff.). Allerdings wird die Urteilsfähigkeit **vermutet** (vgl. 5A_272/2017, E. 5.3.; BSK ZGB I-FANKHAUSER, Art. 16 N 47). Die Urteilsfähigkeit wird je im Zeitpunkt des in Frage stehenden Verhaltens nach den konkreten Umständen beurteilt. Es gilt die Relativität der Urteilsfähigkeit. Diese gilt einerseits zeitlich, sodass sie zum einen Zeitpunkt gegeben sein kann, zum anderen hingegen nicht (z.B. nicht während dem Zustand der Trunkenheit). Des Weiteren beurteilt sich die Relativität auch in Bezug auf das in Frage stehende Geschäft bzw. die in Frage stehende Handlung (vgl. hierzu nur BSK ZGB I-FANKHAUSER, Art. 16 [Seite 234] N 34 ff.). Im Schweizer Recht gibt es für die Beurteilung der Urteilsfähigkeit von Kindern keine feste Altersgrenze (vgl. hierzu m.N. BK-BREHM, Art. 41 OR N 182). In der Lehre ist es umstritten, ob es verschiedene Abstufungen der Urteilsfähigkeit gibt (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 181 ff.; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.09; FELLMANN/KOTTMANN, N 577). Das BGer scheint dies zu bejahen (vgl. BGE 102 II 363). Diesem Streit kommt im Haftpflichtrecht jedoch kaum praktische Bedeutung zu (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 181b; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.09). Die Streitfrage ist denn auch insofern irrelevant, als einer reduzierten Urteilsfähigkeit bei der Schadensbemessung Rechnung getragen werden kann (BK-BREHM, Art. 41 OR N 181b).

Die objektive Seite des Verschuldens kann in zwei Formen auftreten: **Vorsatz** und **Fahrlässigkeit**. Im Gegensatz zum Strafrecht ist im Zivilrecht (und damit im Haftpflichtrecht) die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht von grosser Bedeutung; bedeutsamer ist die Unterscheidung zwischen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit auf der einen Seite und leichter Fahrlässigkeit auf der anderen Seite (vgl. z.B. Art. 100 Abs. 1; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.11).

Vorsatz bedeutet Wissen und Wollen des Erfolges, d.h. der Rechtsgutsverletzung. Eventualvorsatz, d.h. billigendes Inkaufnehmen eines Erfolges, wird im Rahmen der Haftungsbegründung gleich gewertet wie direkter Vorsatz (REY/WILDHABER, N 1000). Zivilrechtlich ist Absicht als Synonym zum Vorsatz zu betrachten (vgl.

SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.13; ROBERTO, Haftpflichtrecht, N 07.22; diff. REY/WILDHABER, N 995 ff.).

Fahrlässigkeit definiert sich als Ausserachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 22.14). Im Zivilrecht gilt ein objektivierter Fahrlässigkeitsmassstab (vgl. **BGE 116 Ia 162** E. 2c). Abzustellen ist dementsprechend nicht auf die individuellen Fähigkeiten des Schädigers, sondern auf die typischen Fähigkeiten, welche ein vernünftiger Angehöriger (*«reasonable person»*) einer bestimmten Berufsgruppe bzw. eines bestimmten Verkehrskreises hat. In diesem Sinne stellt das BGer auf das hypothetische Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers ab. Jede negative Abweichung von diesem geforderten Durchschnittsverhalten gilt als fahrlässig (BGer **4A_22/2008**, E. 4.). 33

Das Gesetz unterscheidet grundsätzlich zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit (vgl. z.B. Art. 100, ebenso Art. 44 Abs. 2). In der Rsp. und Lehre ist darüber hinaus auch die Zwischenstufe der mittleren Fahrlässigkeit anerkannt (vgl. **BGE 100 II 332** E. 3a; REY/WILDHABER, N 1019 m.w.N.). Im Bereich der Haftungsbegründung ist die Unterteilung dogmatischer Natur. Eine Rolle spielt sie jedoch bei der Schadenersatzbemessung. So kann das Gericht bei einer Notlage des Schädigers die Ersatzpflicht gem. Art. 44 Abs. 2 (einzig) dann mässigen, wenn dieser weder absichtlich noch grobfahrlässig handelte. **[Seite 235] Grobe Fahrlässigkeit** liegt vor, wenn jemand jene elementarsten Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt hätte (**BGE 118 V 305** E. 2a; **119 II 443** E. 2a; BGer **4C.92/2007**, E. 3.2; «wie konnte man nur»). **Mittlere Fahrlässigkeit** liegt vor, wenn das Verschulden, ohne leicht zu sein, nicht derart gravierend ist, dass die Anwendbarkeit von Art. 44 Abs. 2 ausgeschlossen ist (**BGE 100 II 332** E. 3a; «das hätte nicht passieren dürfen»). **Leichte Fahrlässigkeit** liegt demgegenüber vor, wenn die Sorgfalt nur geringfügig verletzt wurde (REY/WILDHABER, N 1022; «das hätte jedem passieren können»). 34

Zum Verhältnis zwischen Verschulden und Widerrechtlichkeit vgl. N **26**. 35

3. Rechtsfolgen

Sind die Voraussetzungen der schädigenden Handlung, des Schadens, des Kausalzusammenhangs, der Widerrechtlichkeit sowie des Verschuldens erfüllt, so sieht Art. 41 Abs. 1 als Rechtsfolge die **Verpflichtung zu Schadenersatz** vor. Zur Berechnung des Schadenersatzes vgl. Art. 42; zu Art und Umfang des Schadenersatzes vgl. Art. 43. Es ist zu beachten, dass Schadenersatzpflicht nicht automatisch bedeutet, dass der volle Schaden ersetzt werden muss (vgl. BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 222c); so sind insb. die Herabsetzungsgründe gem. Art. 44 (vgl. hierzu nachfolgend Art. 44) zu beachten, vgl. für den Fall mehrerer Schädiger Art. 50 und 51 (BK-BREHM, **Art. 41 OR** N 227 f.; **BSK OR I-KESSLER**, **Art. 41 OR** N 54). 36

II. Vorsätzlich sittenwidrige Schädigung (Abs. 2)

1. Charakter der Norm

Art. 41 Abs. 2 enthält eine Anspruchsnorm für **sittenwidrige Schädigungen**. Aufgrund des Verzichts auf das Element der Widerrechtlichkeit eignet sich diese Norm v.a. für eine Haftungsausdehnung auf solche Fälle, wo zwar keine Widerrechtlichkeit vorliegt, das Rechtsgefühl aber dennoch eine Ersatzpflicht verlangt (vgl. **BGE 108 II 305** E. 2c). Wegen des Wegfalls des Erfordernisses der Widerrechtlichkeit hat diese Norm insb. Bedeutung für die Ersatzpflicht für reine Vermögensschäden (SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.01). Der praktische Stellenwert dieser Best. ist gering geblieben, so soll sie denn auch nur ausnahmsweise und mit grösster Zurückhaltung angewendet werden (**BGE 124 III 297** E. 5e; **114 II 91** E. 4a). Demgemäss ist die grundsätzliche Daseinsberechtigung dieser Norm in der Lehre 37

umstritten (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 235 ff. m.w.N.). In der Tat ist ein spezieller deliktsrechtlicher Vorsatztatbestand in einem System mit Generalklausel ein eigentlicher Fremdkörper (so auch WIDMER, ZBJV 1994, 400). Zudem nimmt die Bedeutung dieses Spezialtatbestandes heute durch eine Ausdehnung des Widerrechtlich [Seite 236] keitsbegriffes oder die Annahme neuer Haftungsgrundlagen (z.B. Vertrauenshaftung) weiter ab (i.d.S. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.01). Rechtshistorisch geht diese Haftungsfigur auf die *actio doli* des römischen Rechts zurück; sie findet sich ebenso in § 826 BGB, wobei ihre praktische Bedeutung im deutschen Recht weit grösser ist. Im *common law* erfüllt die *tort of deceit* die gleiche Aufgabe.

2. (Haftungs-)Voraussetzungen

Die Haftungs Voraussetzungen gem. Abs. 2 sind tlw. identisch mit denjenigen von Abs. 1 (vgl. BK-BREHM, Art. 41 OR N 238). Dies betrifft insb. die Voraussetzungen der schädigenden Handlung, des Schadens sowie der Kausalität. Anstelle der Widerrechtlichkeit ist **Sittenwidrigkeit** (Verstoss gegen die guten Sitten) erforderlich. Zudem verlangt der Gesetzestext **Absicht**. 38

Der Begriff des Verstosses gegen die guten Sitten bzw. der **Sittenwidrigkeit** ist schwierig zu definieren, da schon der Begriff der Sitten an und für sich dem Wandel der Zeit unterworfen ist (vgl. nur BK-BREHM, Art. 41 OR N 241). Der Begriff entspricht demjenigen von Art. 20 Abs. 1 (HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 7 N 4; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.03). Im Einklang mit einer alten Formulierung des Deutschen Reichsgerichts ist aber davon auszugehen, dass gegen die guten Sitten verstösst, wer das «Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden» verletzt (vgl. den Nw. bei BK-KRAMER, Art. 19/20 OR N 170; ähnl. auch BGE 132 III 455 E. 4.1). Erforderlich sind besonders stossende Bedingungen (BGE 108 II 305 E. 2c). Die Generalklausel der Sittenwidrigkeit muss v.a. durch die Bildung von Fallgruppen konkretisiert werden (so ausdrücklich SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.03). 39

In subjektiver Hinsicht verlangt Art. 41 Abs. 2 eine absichtliche Schadenszufügung. Die h.L. geht davon aus, dass dabei alle Vorsatzarten, nicht aber Fahrlässigkeit, umfasst sind (REY/WILDHABER, N 954 m.w.N.; vgl. schon N 32). Damit bildet Art. 41 Abs. 2 eine **Vorsatzhaftung**. 40

In der Literatur wurden insb. vier **Fallgruppen** herausgearbeitet (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.05 ff.). Es sind dies die Verleitung zum Vertragsbruch (BGE 137 III 293 E. 2.1; 114 II 91 E. 4a/aa), unlautere Einwirkungen auf das Ergebnis von Versteigerungen (*pactum de licitando* bzw. *non licitando*; BGE 109 II 123 E. 2b), grundlose Ablehnungen eines Vertragsschlusses im Falle einer Monopol- oder marktbeherrschenden Stellung (BGE 80 II 26 E. 4c) und der Missbrauch einer formalen Rechtsstellung (vgl. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, N 51.09). Hingegen fällt der Boykott nicht mehr unter den Anwendungsbereich von Art. 41 Abs. 2, da mit dem Kartellgesetz eine vermögensschützende Norm besteht, welche die Widerrechtlichkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 begründen kann. Die wohl wichtigste Bedeutung hat Art. 41 Abs. 2 beim **Doppelverkauf**. Der Anspruch auf Erfüllung eines Vertrages ist zwar [Seite 237] ein relatives Recht, das grundsätzlich nur gegenüber der verpflichteten Partei und nicht gegenüber einem Dritten geltend gemacht werden kann. Der Dritte wird indes dann nach Art. 41 Abs. 2 haftbar, wenn besondere Umstände vorliegen (BGer 4C.273/2002, E. 3.2). Sittenwidrigkeit ist insb. dann anzunehmen, wenn der zweite Kaufvertrag mit dem gemeinsamen Zweck abgeschlossen wurde, die Erfüllung des ersten Kaufvertrages zu vereiteln bzw. die Eigentumsübertragung an den Erstkäufer zu verhindern (BGer 4C.273/2002, E. 3.3). 41

3. Rechtsfolgen

Im Einklang mit Art. 41 Abs. 1 ist auch im Falle der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung **Schadenersatz** als Rechtsfolge geschuldet. Im Falle der grundlosen 42

Ablehnung eines Vertragsschlusses durch eine Anbieterin einer Monopol- oder marktbeherrschenden Stellung kann die Rechtsfolge auch in einem Kontrahierungszwang bestehen (BGE 129 III 35 E. 6.3). Insbesondere beim sittenwidrigen Doppelverkauf kann das Gericht sodann in Anwendung von Art. 43 auf Naturalrestitution erkennen. Dem geschädigten Erstkäufer kann somit ein Anspruch auf Herausgabe der Sache gegenüber dem Zweitkäufer und Erwerber eingeräumt werden (BGer 4C.273/2002, E. 3.2).